

《【문제16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제1심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첩부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1주일 이내에 `항고장`을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음2) 즉시항고를 제기한 丙의 사례와 관련하여, 민사소송법 제445조에 규정된 `항고이유서 제출 기한`의 성질과 이를 준수하지 못했을 때의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 설명하고, 丁의 주장대로 항고이유서 미제출을 이유로 곧바로 항고각하 결정을 내릴 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제16.2의 물음2> 즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 소송비용액확정 결정에 대하여 즉시항고를 제기하면서 항고장에는 항고이유를 기재하지 않았으나 항고장을 제출한 후 10일 이내에 항고이유서를 제출하였고, 丁은 이를 이유로 항고가 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <민사소송법 제445조상 항고이유서 제출기한의 성질과 그 기한을 준수하지 못한 경우의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 항고이유서 미제출만을 이유로 곧바로 항고각하를 할 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고이유서 제출기한의 법적 성질과 미제출 시의 효과 및 항고각하 가능 여부를 기술한다.

II. 즉시항고와 항고이유서 제출

1. 즉시항고이유서 제출 기한 [민사소송법 제445조]

- "민사소송법 제445조"는 즉시항고를 제기할 때 항고장에 이유를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 2002년 민사소송법 개정 당시 즉시항고 절차의 신속성을 도모하기 위해 신설된 규정이다.

2. 제출 기한의 성질

(1) 혼시적 규정 여부

- 항고이유서 제출 기한인 10일이 불변기간인지, 아니면 단순한 혼시규정인지가 문제 된다. "판례"와 통설은 이 기한을 준수하지 않았다고 하여 곧바로 항고를 각하할 수 있는 강제적인 집행력을 가진 기간으로 보지 않는다.

(2) 항소절차와의 비교

- 항소의 경우, 항소장에 이유를 적지 않았더라도 항소기록송부 통지를 받은 날로부터 20일이라는 엄격한 항소이유서 제출 기한이 있고, 이를 어길 시 항소각하 판결을 하도록 규정되어 있다.("민사소송법 제427조", "제429조") 그러나 항고 절차에는 이와 유사한 각하 규정이 존재하지 않는다.

III. 항고이유서 미제출 시의 효과

1. 법적 근거의 부재

- 민사소송법은 항소나 상고의 경우 이유서 미제출 시의 각하 규정을 명시하고 있으나, 항고 절차에서는 "민사소송법 제445조"를 위반하여 10일 이내에 이유서를 제출하지 않은 경우에 대한 제재 규정을 두고 있지 않다. 따라서 조문의 문언상 기한 도과만으로 항고가 부적법해진다고 단정하기 어렵다.

2. 법원의 심리 의무

- 항고법원은 항고이유서가 기한 내에 제출되지 않았더라도, 항고장에 기재된 내용이나 기록에 나타난 자료를 바탕으로 원심재판의 당부를 심사하여야 한다. 만약 항고이유가 전혀 나타나지 않는다면 보정을 명하거나 심리 절차를 통해 이유를 소명할 기회를 주어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 丙의 항고이유서 제출의 효력

- 사안에서 丙은 즉시항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하였다. 이는 "민사소송법 제445조"에서 정한 기간을 준수한 것이며, 설령 이 기간을 도과하여 제출하였다 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 항고 자체가 부적법해지는 것은 아니다.

2. 丁의 주장에 대한 판단

- 丁은 항소이유서 제출 절차를 유추 적용하여 丙의 항고가 부적법하다고 주장한다. 그러나 항고 절차는 항소 절차와 달리 이유서 미제출에 따른 각하 규정이 없으며, 제445조의 기한은 절차의 신속을 위한 권고적 성격이 강하다. 따라서 丙이 이유서를 기한 내에 제출했는지 여부와 상관없이, 이유서가 제출된 이상 법원은 그 내용을 심리해야 하므로 丁의 주장은 타당하지 않다.

V. 결론

- 즉시항고에서 항고이유서 제출 기한(10일)은 항소이유서와 달리 그 미준수 시 각하를 강제하는 효력이 없다. 따라서 丙의 항고는 적법하며, 법원은 丁의 주장대로 항고이유서 제출 시점을 이유로 항고를 각하할 수 없다. 법원은 丙이 제출한 항고이유서를 바탕으로 소송비용액확정 결정의 정당성을 실질적으로 심리하여야 한다.